

1503282-65.2021.8.26.0024

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Pedro Luiz Fernandes Nery Rafael

Comarca: Andradina

Foro: Foro de Andradina

Vara: 3ª Vara

Data de Disponibilização: 25/07/2022

... dúvidas de que a imputação do delito de roubo majorado é procedente.

De início, quanto à consumação do roubo, a jurisprudência do STJ, consolidou o entendimento no sentido da adoção da teoria da apprehensio ou amotio, segundo a qual se considera consumado o delito no momento em que o bem subtraído passa para a esfera de domínio do agente, ainda que por breve espaço ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Andradina

Foro de Andradina

3ª Vara

Rua Paes Leme, 2052, Andradina-SP - cep 16901-110

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1503282-65.2021.8.26.0024 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1503282-65.2021.8.26.0024

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Portaria - 2348728/2021 - DEL.POL.CASTILHO, 16231121 - DEL.POL.CASTILHO, 2348728 - DEL.POL.CASTILHO

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

Autor Desconhecido 1 e outros

Réu Preso

Prioridade Idoso

O Ministério Público ofereceu denúncia contra JEFERSON CARLOS SOUZA OLIVEIRA, LUÍS GUSTAVO DA SILVA e TAYMISON FELIPE DIOGO SABINO imputando-lhe a prática do crime de roubo majorado (art. 157, §§ 2º, II e VII, e 2º-A, I, c/c 29, caput, ambos do Código Penal).

Narra a denúncia que no dia 07 de dezembro de 2021, por volta das 20h07min, no Sítio São Bom Jesus, lote 26, na cidade de Castilho, nesta comarca de Andradina: os réus, qualificados respectivamente às fls.24, 151 e 155/157; fls.86, 121 e 161/163; e fls.124, 126 e 158/160 dos presentes autos, agindo em concurso e com unidade de desígnios, subtraíram para si a quantia de R\$ 500 em dinheiro, um aparelho de telefonia celular, da marca "Samsung", modelo "A10", e um frango congelado, ainda não avaliados, pertencentes a Neusa Lindolfo dos Santos, mediante o emprego de grave ameaça contra ela e Domingos Antonio Baccini Junior, pelo uso de arma de fogo e de arma branca (faca).

A denúncia foi recebida em 04 de março de 2022 em decisão de fls.183/185. Os réus foram citados e apresentaram resposta à acusação de fls.248/249 e 258/265.

Após regular instrução, o Ministério Público manifestou-se pela condenação, entendendo demonstradas a materialidade e autoria do delito imputado; as d.

Defesas, por sua vez, pronunciaram-se no seguinte sentido: i) Luís Gustavo da Silva requereu a absolvição por insuficiência probatória da participação do corréu no

ato, sendo mentirosas as declarações de Taymison prestas na fase policial e, subsidiariamente, aplicação da pena no mínimo legal e concessão de regime menos gravoso, além de substituição da pena e direito de recorrer em liberdade; ii) Jeferson Carlos Souza Oliveira requereu a absolvição também por insuficiência de provas e ausência de dolo, ou reconhecimento da participação de menor importância, também fazendo pedidos sobre eventual aplicação da pena, detração desta e expedição de alvará de soltura; iii) Taymison Felipe Diogo Sabino alegou ausência de dolo por conta de ter praticado o fato em estado de embriaguez, requereu a consideração da confissão espontânea, apontou que não houve perícia na arma de fogo utilizada, requereu desclassificação de roubo para furto, tecendo considerações sobre a dosimetria da pena, regime aplicável e pedido de recurso em liberdade.

É o relato do necessário. Fundamento e DECIDO.

Inexistem nulidades ou irregularidades a serem sanadas. O feito tramitou regularmente. Não foram arguidas preliminares ou questões prejudiciais aptas a impedir o prosseguimento da marcha processual, razão pela qual passo à análise do mérito da lide.

Após detida análise das provas produzidas e sopesadas as alegações das partes, conclui-se pela procedência da acusação.

Com efeito, a ocorrência do delito foi demonstrada pelos elementos da investigação (inquérito policial de fl.01, portaria de fl.02, boletim de ocorrência de fls.03/04, 82/83, 99/100 e 142/143, termo de declarações de fl.12, 15, 19/20, 24, 121, 124/125, 136 e 151/152, laudos periciais de fls.323/328), bem como pelo resultado da instrução em juízo.

A autoria também foi comprovada pelos elementos indicados, assim como pela prisão em flagrante e consistentes relatos das testemunhas.

A prova oral, produzida sob o crivo do contraditório, foi no seguinte sentido:

A vítima Neusa Lindolfo dos Santos narrou que estavam na varanda do sítio e viram um carro preto "devagarinho", que passou e voltou. O Domingos falou que era carro de "ladrão". De repente chegaram dois armados, com revólver, botaram na cabeça e falaram para ficarem quietos. Foram para dentro e eles ficaram exigindo dinheiro. Ficou com medo de morrer, e tirou R\$ 500,00 da bolsa e deu para o assaltante. Falou que o indivíduo estava violento e perguntou o que faria com a depoente caso achasse mais dinheiro. Em seguida, o assaltante pediu seu celular, o qual fazia 3 meses que tinha comprado, por R\$ 1.300,00. Ficou muito nervosa na hora. Eles entraram no outro quarto pegaram 2 pacotes de cigarro Eight, um pacote de fumo Jaú, mais alimentos na geladeira. Pegaram a chave, trancaram por fora e foram embora. O Domingos estava no banheiro e conseguiu sair. Falou que 8 dias antes, esse carro já tinha passado ali, mas por distração não havia percebido. Disse que ambos estavam com arma de fogo. Eles estavam encapuzados. Falou que um dos indivíduos era baixo, meio gordinho - o que ficou consigo. O outro mais alto e magro, que ficou com Domingos. Recuperou apenas o aparelho celular. Na delegacia não efetuou reconhecimento. Disse que do local onde o carro passou para onde estavam a distância é de cerca de 6 a 7 metros. O veículo era um gol preto. Falou que no momento não reconheceu os assaltantes, mas depois de uns 3 dias, refletindo sobre os trejeitos e características, notou semelhança entre o assaltante grandão, alto, e o acusado Taymison, de apelido "Cotô", o qual trabalhou bastante tempo com Domingos em uma construção próxima. Em ato de reconhecimento, apontou os corréus Jeferson e Luís Gustavo como autores da ação.

A também vítima Domingos Antonio Baccini Júnior, confirmou a versão da vítima Neusa, sem divergências ou acréscimos dignos de nota, apenas afirmando que nada de sua propriedade foi subtraído, e que tem certeza de que o veículo que passou dias antes é o mesmo que passou no dia dos fatos, um Gol preto. Em ato de reconhecimento, apontou os réus Taymison e Luís Gustavo como autores da ação.

A testemunha e policial militar Edivander, contou que foram acionados para atender ocorrência de roubo a propriedade rural. Ao chegar no local, fizeram contato com as vítimas, que relataram que indivíduos passaram em um veículo Gol Preto em frente à residência, que parou a 50 metros da entrada. Quando perceberam dois indivíduos chegaram e anunciaram o roubo. Em certo momento, a vítima disse que foi obrigada a entrar dentro banheiro (senhor) e a outra entregou valores, cigarros e pacote de

fumo. Os dois estavam encapuzados, portando pistola e revólver e outro teria ficado no veículo. Não conseguiram localizar ninguém nas proximidades. A investigação prosseguiu com a polícia civil. Com relação aos outros roubos, houve registro de BOPM – um mercado, sendo que pela aparência parecia ser o Taymison. Da casa à estrada tem cerca de 10 a 15 metros. A estrada é Castilho-Junqueira. A vítima informou apenas que era um Gol preto.

Samuel Piovesan, testemunha e policial civil, relatou que no final do ano passado, começou uma "onda" de roubo a mão armada em Castilho. Algumas ocorrências eram "individuais" e outras em concurso de pessoas. Dentre uma das ocorrências, o possível suspeito foi flagrado por câmeras de um estabelecimento, fugindo em uma bicicleta vermelha, deixando cair uma possível arma de fogo. O setor de investigações de Castilho recebeu informações de que poderia ser o acusado Taymison e fizeram diligências para confirmar tal suspeita. No endereço em que constava no sistema, era a casa da mãe do acusado, sendo que esta relatou que o filho estava em local incerto, sendo que havia tempos que não o via. Ela viu o vídeo de monitoramento e reconheceu como sendo seu filho. Conseguiram levantar outro endereço e a proprietária, posteriormente, informou a polícia de que pessoas ligadas a Taymison estavam lá no local retirando pertences. Foram ao local e conseguiram localizar uma bicicleta, a qual foi apreendida. Entraram em contato com uma das vítimas, proprietário do mercado, onde havia as câmeras, e ele reconheceu a bicicleta. Na continuação, receberam informação de que Taymison tinha trabalhado como pedreiro em um sítio na zona rural. Foram até o proprietário do sítio, mostraram uma foto, e ele confirmou que ele havia trabalhado na construção, dizendo que o sítio que foi roubado, da dona Neusa, é vizinho da construção. Conversaram com a dona Neusa, mostrando o vídeo do roubo do mercado, e ela confirmou que parecia ser o Taymison um dos autores. Chegaram à conclusão de que as suspeitas se confirmaram contra Taymison. Em janeiro Taymison foi preso em decorrência de mandado de prisão e, em declarações, ele assumiu a autoria e citou Jeferson e Luís Gustavo como partícipes do caso do sítio. Nestas declarações, ele disse que foi à casa de Jeferson, proprietário do Gol preto, e junto foi o Luís Gustavo, seu cunhado. No local, Taymison e Luís Gustavo entraram, e Jeferson ficou no veículo. Taymison ficou responsável pelo Domingos e Luís ficou com a Dona Neusa, pegando dinheiro e celular, repassando para Taymison. Terminaram a conduta, entraram no Gol, e dirigiram-se a Castilho. No caminho houve a partilha dos valores. Com Jeferson nada foi apreendido. Após a prisão, não se recorda de qual dos acusados, conseguiram recuperar o celular subtraído. A pessoa que estava em posse do celular disse que havia comprado do Taymison. Disse que, da estrada principal, ao sítio da Dona Neusa, deve dar uns 3 quilômetros até a estrada de terra. Essa estrada municipal dá acesso ao bairro Junqueira. O bairro Laranjeira é por estrada totalmente diversa.

A também testemunha e polícia civil Flavia Fernanda Novaes da Silva, confirmou a versão de seu colega de profissão, sem divergências ou acréscimos dignos de nota. A testemunha Solange Cristina da Rocha Silva disse que conhece a mãe de Jeferson, há 10 anos. Disse que Jeferson possui um veículo, o qual não é barulhento. Nunca soube ser Jeferson dado a práticas ilícitas. Ele tem uma filha pequena, à qual sempre foi muito dedicado. Relatou que ele sempre trabalhou, inclusive na Usina. O carro que o acusado possui é um Gol preto.

Ouvido como informante, Roberto Urbano Aguiar, disse que é padraсто do acusado Jeferson, sendo que convive com a mãe dele há 20 anos. Nunca soube de qualquer prática de ilícito por Jeferson. Ele sempre trabalhou e possui uma filha. O Jeferson possui um veículo Gol, silencioso.

O corréu Taymison Felipe Diogo Sabino confessou os fatos, mas negou a participação de Luís Gustavo ou Jeferson. Disse que praticou o ato apenas com um rapaz de Andradina, o qual tem um veículo Gol verde. Na delegacia, indicou Luís Gustavo e Jeferson como participantes por conta de um desentendimento que houve no dia dos fatos, porque eles não queriam lhe entregar dinheiro, R\$ 350,00, para comprar drogas.

Por sua vez, o acusado Luís Gustavo da Silva negou os fatos. Sobre a acusação feita por Taymison em sede policial, a atribuiu por conta de um desentendimento que teve

com Taymison, porque em uma ocasião posterior aos fatos ele ingressou na sua casa de forma desrespeitosa (o que era corriqueiro), surpreendendo o depoente e sua esposa em situação de privacidade e pela repetição de tais atos o repreendeu. Confirmou que Taymison levou um frango para ficar na sua casa e que a discussão ocorreu depois de quando Taymison levou o frango para sua casa. Negou que Taymison tenha lhe pedido dinheiro, dizendo que o ajudava materialmente com guarda de alimentos e serviços, mas não com dinheiro. Falou que tinha uma relação boa com Taymison, mas não de amizade, eram "chegados". A única discussão que teve com Taymison foi por conta da entrada não autorizada na residência. Disse que já foi vizinho de Jeferson, o qual tinha um veículo Gol de cor preta. Falou que, no dia da entrega do frango, o Taymison estava de bicicleta. Reiterou que Taymison pedia mais ajuda em serviços e alimentação, mas não dinheiro vivo. Falou que foi preso em seu trabalho.

Jeferson Carlos Souza Oliveira também negou a participação nos fatos. Reconheceu ter dado carona para Taymison, mas para o Bairro Laranjeiras, lugar distinto de onde ocorreu os fatos, e em outra data, distinta do dia dos fatos, mas não soube precisar se anterior ou posterior aos fatos. Falou que até o dia 07/12, dia dos fatos, conhecia Taymison apenas de vista, mas ele nunca tinha ido a sua casa. Confirmou a propriedade de um veículo Gol preto. Questionado, disse que nunca teve problemas com Taymison, não sabendo dizer por qual razão ele teria incriminado sua pessoa. Falou que trabalhou em diversos locais, inclusive na Usina Viralcool. Diante desse contexto probatório, não há dúvidas de que a imputação do delito de roubo majorado é procedente.

De início, quanto à consumação do roubo, a jurisprudência do STJ, consolidou o entendimento no sentido da adoção da teoria da apreensão ou amotio, segundo a qual se considera consumado o delito no momento em que o bem subtraído passa para a esfera de domínio do agente, ainda que por breve espaço de tempo. Não há a necessidade de o agente ter a posse mansa e pacífica do objeto para configurar o delito. Foi justamente o que ocorreu nos autos.

Confira-se o teor da súmula 582 do C. STJ: "Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada".

Veja-se que as vítimas narraram minuciosamente e em uníssono que foram abordadas por dois indivíduos armados, os quais as subjugaram e de forma violenta, subtraíram bens e se evadiram. Indicaram que um veículo Gol de cor preta, que já tinha ido ao local dias antes, foi por eles visto logo antes da ação criminosa, presumindo-se então que os assaltantes dele desembarcaram.

Em sede policial, o acusado Taymison confessou os fatos e indicou os corréus Luís Gustavo e Jeferson como coautor e partícipe do crime, de forma detalhada.

Ambas as vítimas, em ato de reconhecimento realizado com 4 pessoas, indicaram Luís Gustavo como um dos autores da ação. O procedimento revestiu-se de todas as formalidades do art. 226 do CPP.

Em juízo, Taymison isentou Luís Gustavo e Jeferson de participação no crime, apontando que os acusou por raiva em razão de um desentendimento que ocorreu no dia dos fatos, porque havia pedido dinheiro emprestado a ambos (foi primeiro na casa de Luís e depois na casa de Jeferson), os quais lhe negaram auxílio.

Ocorre que Luís Gustavo narrou que não se recordava de Taymison ter lhe pedido dinheiro, e disse que a acusação ocorreu por conta de uma briga que tiveram em data posterior ao crime, e por outro motivo, não indicado por Taymison. Há dupla divergência: sobre o motivo da desavença e também sobre a data desta (Taymison alega que foi imediatamente anterior ao crime; Luís Gustavo relatou que foi em data posterior ao fato).

Jeferson, por sua vez, negou ter tido qualquer desentendimento com Taymison. Assumiu ser proprietário de um Gol preto, e falou que até o dia dos fatos só conhecia Taymison "de vista", sendo que ele nunca havia ido a sua casa. Disse ainda que deu uma carona para Taymison, mas para outro local, mas não se recordava se antes ou depois do fato (contrariando sua própria fala de que até o dia dos fatos só conhecia Taymison de vista). Novamente, bastante divergente o depoimento das

declarações de Taymison.

Assim, vê-se que as provas são amplamente desfavoráveis aos réus. A narrativa das vítimas a indicar o veículo de propriedade de Jeferson como tendo indo ao local dias antes e no dia do crime, logo antes da ação, o reconhecimento efetuado por ambas em relação a Luís Gustavo, a indicação detalhada por Taymison na fase investigativa sobre como Jeferson e Luís o ajudaram na empreitada, o fato de Luís Gustavo estar com o alimento subtraído (frango) em sua própria residência logo após os fatos, e a inexplicável divergência de versões e desencontro de informações nos interrogatórios dos três corréus, como apontado acima, são elementos suficientes para reconhecimento da responsabilidade criminal dos três.

Anoto, ainda, que a versão prestada por Taymison de que praticou o fato com um desconhecido, que tinha um veículo Gol verde, é de toda inverossímil. A uma porque não indicou maiores detalhes de como se deu tal ação com um desconhecido. A duas porque é extremamente improvável que fossem em local ermo, em apenas dois agentes e sem maior planejamento, deixando o veículo automotor longe do local do crime, o que seria muito arriscado. Em ações desta natureza, os criminosos comumente valem-se do denominado "cavalo", agente que fica no veículo pronto para prestar imediata fuga aos comparsas que executam a ação.

Aproveitando o raciocínio, certo que não há que se falar em participação de menor importância ou "delito privilegiado" praticado por Jeferson, dada a relevância da ação daquele que leva os executores (notadamente no caso dos autos, em que os fatos se deram em local distante da cidade) e propicia pronta fuga a eles após a ação. E Taymison não teria mesmo razões para incriminar indevidamente Luís Gustavo e Jeferson, pessoas de seu convívio, o que fez impensadamente na fase policial, mas posteriormente arrependeu-se, por razões óbvias, mas injustificadas do ponto de vista técnico e lógico.

As alegações defensivas de que Taymison não agiu com dolo por estar embriagado devem ser de plano rechaçadas. A uma porque, como se sabe, eventual estado de embriaguez não interfere no dolo, em razão da adoção da teoria da *actio libera in causa*. Aquele que se embriaga o faz consciente dos riscos do consumo de substâncias psicoativas, entendendo-se que suas ações posteriores devem lhe ser imputadas normalmente, por mais que sua consciência possa estar alterada (aliás, muitas vezes a própria lei estabelece consequência mais severa ao estado de embriaguez, como no CP 61, II, 'I'). Em uma palavra: a embriaguez não interfere no dolo. No máximo, poderia ser analisada na etapa da culpabilidade; entretanto, como se sabe, a embriaguez não exclui a imputabilidade, na forma do CP 28, II. Trata-se, ademais, de embriaguez voluntária.

No que diz respeito a necessidade de exame toxicológico, anoto que i) a defesa não requereu a providência em nenhum momento, seja na defesa prévia, seja ao final da audiência quando questionadas as partes se possuíam outras provas a produzir ou requerimentos na fase do CPP 402, inovando em sede de alegações finais quando já finda a etapa própria para produção de provas, o que não se pode admitir, ainda mais sob a alegação de que há prejuízo à própria defesa que não requereu a medida (CPP 565); ii) seria impossível a realização de tal exame após vários meses do fato.

Também não houve nenhum elemento ou indício mínimo de estado de inimputabilidade ou semi-imputabilidade do corréu, devendo-se considerar portanto plenamente imputável.

No que toca à alegação de ausência de apreensão da arma de fogo, cabe menção à consolidada jurisprudência do C. STJ, no sentido de sua desnecessidade, quando elementos outros de prova se afirmarem quanto ao emprego do artefato lesivo (AgRg no HC 699286/SP - 6ª Turma - Julgado em 28/06/2022): "Consoante jurisprudência pacífica desta Casa, é dispensável a apreensão e perícia da arma utilizada no delito de roubo, 'quando evidenciada sua utilização por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas' (AgRg no AREsp 1.577.607/DF, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 9/3/2020)".

No mesmo passo, não há que se falar em desclassificação para furto, pois além da demonstração de que houve emprego de duas armas de fogo, as vítimas foram categóricas (especialmente Neusa) a relatar a agressividade dos executores do crime, caracterizada então a grave ameaça, elementar do art. 157 do CP.

Sendo assim, é de ser acolhido o pleito do Ministério Público para condenação dos acusados, cabendo reconhecimento das causas de aumento relativa ao concurso de agentes e arma de fogo (pois as duas vítimas narraram que se tratavam de armas de fogo, sendo prescindível a respectiva apreensão, nos termos de iterativa jurisprudência).

Impondo-se a condenação, resta a fixação da sanção correspondente.

Critérios para fixação da pena:

Antes de iniciar a fixação da pena propriamente dita, cabem alguns esclarecimentos sobre os critérios gerais a serem utilizados para a dosimetria, especialmente sobre a forma de cálculo das frações de aumento e diminuição. A base de cálculo será o intervalo entre a pena mínima e máxima do delito, e não a pena mínima.

Na primeira fase, na qual fixa-se a pena-base, existem oito circunstâncias judiciais passíveis de valoração. A pena sempre partirá do mínimo previsto e, a cada circunstância judicial desfavorável ao acusado, somar-se-á à reprimenda mínima cominada a fração de um oitavo (pois são oito circunstâncias), calculada pelo intervalo entre o máximo e o mínimo de pena previstos em lei para o crime em questão. A partir deste intervalo entre a pena máxima e a mínima encontra-se a fração respectiva de um oitavo para cada circunstância desfavorável.

Exemplificando-se, para melhor compreensão: se um crime tem pena mínima de 12 anos e máxima de 20 (como ocorre com o tipo previsto no art. 159, § 1º do Código Penal), o cálculo das frações é feito sobre o intervalo de 8 anos entre a pena mínima e máxima, e não sobre os 12 anos da pena mínima. A cada circunstância negativa considerada somar-se-á à pena mínima $\frac{1}{8}$ sobre oito anos, o que representa um ano. Se não houver circunstância negativa, a pena-base será a mínima, de 12 anos; ao contrário, se todas forem desfavoráveis, a pena parte do máximo legal, 20 anos. Tal forma possibilita ao mesmo tempo: i) controle sobre os patamares utilizados pelo julgador, que se move em espaço conferido pelo legislador por meio de critério racional; ii) proporcionalidade, pois cada circunstância terá, em regra, peso semelhante e será calculada de acordo com os patamares mínimo e máximo da pena, abarcando de forma global a gravidade do crime; iii) fixação da pena partindo sempre do mínimo legal, com a possibilidade de se chegar ao máximo previsto, caso as oito circunstâncias judiciais sejam desfavoráveis.

O critério também evita indesejáveis discrepâncias, como nos casos de crimes com pena mínima muito elevada ou diminuída. Se o cálculo partir da pena mínima, pode-se chegar a exasperações exageradas (como no caso da extorsão mediante sequestro seguida de morte, cuja pena mínima é de 24 anos) ou ínfimas (neste caso nunca se chegando perto da pena máxima cominada para o delito, como no crime de ameaça).

Ademais, permite que crimes que possuem a mesma pena mínima, mas diferentes penas máximas, justamente por serem de gravidade distinta (como a lesão corporal do caput e a figura do § 9º), sejam apenados adequadamente, cada um com sua gravidade e grau de censura já estipulados em lei. Seria injusto que para crimes de diferente gravidade a exasperação da pena-base partisse do mesmo patamar.

Via de regra, este será o critério utilizado na primeira fase. Diante da peculiaridade de cada caso as frações de cálculo poderão ser diminuídas ou aumentadas, para que se possa individualizar adequadamente a pena, de forma fundamentada (como por exemplo, nos casos de várias condenações criminais ou reincidência específica). O critério explicitado servirá sempre de parâmetro, porém não impedirá seja a pena-base fixada de modo diverso (para mais ou menos) se o caso assim recomendar (valendo isto também para a segunda fase).

Na segunda fase, na qual incidem agravantes e atenuantes, a fração usada para valoração será, no mais das vezes, de um sexto ($\frac{1}{6}$), calculado ou sobre o intervalo entre pena mínima e máxima, como acima, ou sobre a pena-base já fixada - o que for maior.

E utilizar-se-á o maior valor por uma razão simples: há uma hierarquia no sistema trifásico que deve ser respeitada. O sistema trifásico é escalonado, tendo cada fase maior relevância sobre a precedente. As circunstâncias do art. 59, valoradas pelo julgador, jamais podem preponderar sobre agravantes ou atenuantes, elevando a pena em patamar acima destas, que já foram estipuladas como mais graves de antemão pelo próprio legislador. A fração de $\frac{1}{6}$ será utilizada pois é a menor prevista

para as causas de diminuição e de aumento de pena e, com isso, respeita-se novamente a hierarquia do sistema trifásico.

Por fim, como não poderia deixar de ser, as causas de aumento ou de diminuição de pena incidirão sobre a reprimenda fixada provisoriamente na primeira e segunda fases, de forma sucessiva (incidindo umas sobre as outras, em cascata), segundo entendimento preponderante nos tribunais. Do contrário poderia se chegar ou a penas negativas, no caso de diversas causas de diminuição, ou na utilização de critérios distintos para causas de aumento e de diminuição, o que não é isonômico.

Friso que o critério ora explicitado vem sendo consagrado pelo C. Superior Tribunal de Justiça (HC 498586 / SP - 5ª Turma - julgado em 11/02/2020), verbis:

"2. A individualização da pena é uma atividade vinculada a parâmetros abstratamente cominados pela lei, sendo permitido ao julgador, entretanto, atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada. Dessarte, ressalvadas as hipóteses de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade, é inadmissível às Cortes Superiores a revisão dos critérios adotados na dosimetria da pena.

3. As agravantes não necessariamente incidem sobre o resultado da pena-base, cujo acréscimo de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância negativa multiplica o intervalo de pena decorrente da diferença entre a pena mínima e máxima cominadas ao tipo, para então somar à pena mínima. Portanto, as agravantes incidirão sobre a pena-base se for maior ou igual ao intervalo de pena em abstrato do preceito secundário, caso contrário, malgrado haver pena concreta dosada, as agravantes serão fixadas com parâmetro na base de cálculo das circunstâncias judiciais, sob pena de as agravantes serem menos gravosas do que meras circunstâncias judiciais". E ainda (AgRg no REsp 1704633 / TO - 6ª Turma - julgado em 24/09/2019): "A divisão do intervalo entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato pelas oito circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP é um, entre outros, dos critérios que podem ser utilizados na fixação da pena-base".

Dito isso, passo efetivamente a fixar a pena.

1 - Corrêu Taymison:

Na primeira fase, não vislumbro razões para exasperar a pena-base, a qual fixo no mínimo legal, 4 anos de reclusão, pois as circunstâncias negativas do fato serão valoradas para incidência das duas causas de aumento em sequência na terceira fase. Na segunda fase, incide a agravante relativa ao fato de uma das vítimas ser idosa (Neusa), mas também a atenuante da confissão, preponderante nos termos da jurisprudência do STJ por se relacionar com a "personalidade do agente" (por mais que se discorde da premissa, se trata da posição da Corte que uniformiza a interpretação da lei federal no país) o que mantém a pena no mínimo, nos termos da súmula 231, também do STJ.

Na terceira fase, são duas as causas de aumento, as quais devem incidir em sequência, nos termos da jurisprudência do E. TJSP, sendo mera faculdade do julgador a incidência de apenas uma delas.

Entretanto, tenho que pela gravidade da ação, que envolveu três agentes, e emprego de duas armas, mostra-se mais consentâneo e proporcional a incidência do concurso de agentes em 1/3 e da arma de fogo em 2/3.

Com tais operações, a pena de Taymison vai a 8 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão e 21 dias-multa.

2 - Corrêus Luís Gustavo e Jeferson:

Na primeira fase, fixo a pena no mínimo legal.

Na segunda fase, por conta do crime ter sido cometida contra pessoa idosa, incide a agravante prevista no art. 61, II, 'h', do CP. Utilizo o patamar de 1/6, pelo critério de cálculo acima explicitado (encontro da fração a partir do intervalo entre a pena mínima e máxima do delito), o que representa 1 ano de reclusão e 58 dias-multa, a serem somados à pena-base de 4 anos de reclusão e 10 dias-multa.

Ressalto que NÃO SE TRATA DE UTILIZAÇÃO DO CRITÉRIO DO TERMO MÉDIO (O QUAL FARIA A PENA-BASE PARTIR DE 7 ANOS E NÃO DO MÍNIMO), TAMPOUCO DE ERRO ARITMÉTICO.

Trata-se de utilização de distinta base de cálculo para encontro das frações de mudança da pena, utilizando-se o resultado do intervalo entre a pena mínima e máxima, e não a pena mínima, critério este que considera a gravidade do crime de

forma global conforme estipulada pelo legislador e mostra-se mais proporcional ao juízo prévio feito pelo parlamento sobre a natureza do crime (caso contrário, crimes com pena mínima igual e pena máxima diversas, como o estupro e o homicídio, o furto qualificado e a corrupção passiva, etc, teriam idêntico apenamento, o que não se mostra de fato adequado, pois o legislador já estabeleceu distinção prévia de gravidade, a ser observada pelo julgador; já crimes com penas mínimas muito elevadas, teriam exasperações exageradas, como a extorsão mediante sequestro com resultado morte, com pena mínima de 24 anos).

De toda forma, destaco novamente que o tópico acima ("critérios para fixação da pena") estabelece as justificativas pelas quais a individualização da pena resta melhor assegurada por esta forma de cálculo, que é diferente do padrão normalmente adotado (mais cômodo para cálculos, mas que desconsidera inúmeros fatores de proporção e postulados a respeito da prevalência dos critérios de lei sobre critérios subjetivos), mas que é referendado por argumentos racionais e também pela jurisprudência do STJ (HC 498586/SP – 5ª Turma – julgado em 11/02/2020 e AgRg no REsp 1704633/TO – 6ª Turma – julgado em 24/09/2019).

Na terceira fase, incidem as duas causas de aumento já mencionadas na dosimetria relativa a Taymison e, com os aumentos, as penas chegam a 11 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão e 150 dias-multa.

O regime inicial para todos os réus, tendo em vista a gravidade em concreto do crime e quantidade de pena deve ser o fechado.

Inviável a substituição da pena, pela quantidade de pena e crime cometido com violência e grave ameaça.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a acusação e CONDENO os réus pela prática do crime de roubo majorado, previsto no art. 157, §§ 2º, II e 2º-A, I, c/c 29, caput, ambos do Código Penal, às seguintes penas:

- 1) TAYMISON FELIPE DIOGO SABINO: 8 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão e pagamento 21 dias-multa, no mínimo legal, em regime inicial fechado;
- 2) JEFERSON CARLOS SOUZA OLIVEIRA: 11 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão e pagamento de 150 dias-multa, no mínimo legal, em regime inicial fechado.
- 3) LUÍS GUSTAVO DA SILVA: 11 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão e pagamento de 150 dias-multa, no mínimo legal, em regime inicial fechado.

Os réus responderam ao processo presos e foram condenados a penas altas, por fato bastante grave. Formada sua culpabilidade em juízo de certeza, não vislumbro razões para que sejam postos em liberdade. Anoto que o crime foi cometido com grave ameaça exercida contra pessoa idosa e com emprego de arma de fogo, além do concurso de três agentes, revelando maior reprovabilidade e efetivo risco à ordem pública a soltura dos réus.

Entendo assim, que permanecem os motivos para a prisão preventiva, para garantia da ordem pública. Recomendem-se os acusados no presídio em que se encontram e expeça-se guia de recolhimento.

Condene os réus ao pagamento das custas do processo em 100 UFESPs, com as ressalvas da gratuidade, que fica aqui deferida, em razão das condições socioeconômicas dos acusados.

Com o trânsito, i) comunique-se ao IIRGD e ii) Justiça Eleitoral, ii) anote-se a condenação (art. 372 das NSCGJ) e iv) expeça-se guia de recolhimento.

Oportunamente, expeça-se certidão de honorários ao advogado que atuou pelo convênio.

Corrija-se o polo passivo para que conste apenas os réus JEFERSON CARLOS SOUZA OLIVEIRA, LUÍS GUSTAVO DA SILVA e TAYMISON FELIPE DIOGO SABINO, sem duplicidade.

Publique-se. Intime-se na forma legal.

Andradina, 25 de julho de 2022.

Pedro Luiz Fernandes Nery Rafael
Juiz de Direito
(assinatura eletrônica)